

居间或委托——房地产经纪行为模式再探讨

廖俊平 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任

笔者已经在本专栏多次讨论过房地产经纪佣金问题以及与之密切相关的房地产经纪合同关系或房地产经纪行为模式问题。本期专栏所讨论的问题起源于几天前与一位资深业界人士（下面不妨用广东业界的术语称其为“行家”）的讨论。

这位行家认为：一个经纪人同时代表买卖双方的利益，也就是采用居间方式促成交易，比两个经纪人分别代表买卖双方（即分别接受买方或者卖方的委托，形成委托关系）效率要高。其理由是，居间行为中的关系人有三方，而委托行为中的关系人有四方（买卖双方加上代表买卖各方的经纪人），关系多了一重，效率自然就降低了。

这位行家提出的命题实际上涉及若干层次问题的讨论。

首先，居间方式是否比委托方式的效率高？这个问题比较容易回答——的确是高。

其次，这样的高效率是如何取得的？对这个问题的坦白回答可能就会让人有些尴尬了——事实上，这样的高效率往往是在牺牲买卖双方的其中一方利益的基础上取得的。

此话怎讲？让我们先来看看交易价格是如何形成的。房地产估价理论中有所谓“公开市场价值”的说法，所谓公开市场价值，用通俗的话说就是绝大多数普通人对估价对象的价值判断的平均值，所以也可称之为公平市价。每一个人，包括买卖双方，对于所估价或者所交易的对象都会有自己的价值判断，这可称之为“主观价值”，在达成交易之前的谈判过程中，买卖双方会通过讨价还价最终确定成交价格。如果买卖双方对交易对象的市场信息都有充分的了解，同时又都有足够充分的谈判时间，并且双方都能自主决定交易价

格，那么最终形成的这个交易价格一般就可以认为是“极度接近”公开市场价值的。

从以上对公开市场价值的描述已经可以看出：公开市场价值形成的重要前提是买卖双方对所交易的对象的市场信息都有充分的了解，同时又都有足够充分的谈判时间。但在现实当中，普通的交易当事人往往对市场信息是缺乏了解的，而经纪人则可以认为是对市场信息有充分了解的，如果由经纪人来分别代表买卖双方谈判，就将原本对市场信息不够了解的买卖双方之间的谈判转化成了对市场信息有充分了解的各自代理人之间的谈判，这样形成公平市价的可能性就大大增加了。

而如果采取所谓居间方式，即由一个经纪人来撮合双方成交，那么在价格谈判的过程中经纪人会分别做买卖双方的工作，一方面希望买方提高出价，另一方面希望卖方降低售价，在这个过程中，经纪人为了尽快完成撮合交易，往往是“柿子捡软的捏”，哪一方容易说话（实际上也就是哪一方对市场信息了解的较为不充分）就压这一方让步多一点，这样形成的交易价格就不那么公平了。

其实，这也恰恰是“一肩挑两头”的经纪人在现实中常常为人所诟病的一点：你怎么可能既照顾好买方的利益，同时又照顾好卖方的利益呢？在成交价格这一点上，买卖双方显然是有利益冲突的。

当我用上述理由反驳这位行家以后，他进而提出了这样一个论据：如果能够尽快成交，对于买卖双方来说也是有好处的啊。我明白他所说的意思：时间就是金钱，早日完成交易，能够节约时间，同时能够提高资金（或者房屋）的使用效率，早日创造新的价值。这当然是有道理的，但问题在于：这样的决定应该由买卖双方自己做。经纪人如果

运用附条件合同原理 完善“城中村”改造实施方案

王达 广州大学公法研究中心

当前,各地都在进行“城中村”改造。笔者在指导一些地方政府进行“城中村”改造中探索了协商搬迁模式,该模式在青岛四方区称为自主拆迁、成都称为模拟拆迁,上述模式在法律上都源于附条件合同原理。

附条件合同,是指当事人在合同中特别规定一定的条件,以条件是否成就来决定合同效力的发生或消灭的合同。《合同法》第45条规定:“当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。”在附条件合同中,条件具有限制合同效力的作用。合同中所附的条件,必须是将来发生的事实是不确定的事实。合同中附条件的主要作用在于,可以把当事人的动机反映到合同中,使其具有法律意义。“城中村”改造需要大量资金,地方财政很难提供,常常通过开发企业参与解决。但是,开发企业必然带有商业目的,这就必然出现多方利益博弈。在博弈中和谐地推进“城中村”改造需要将个体协议转

化成群体的一致意见,这需要通过逐一签订协议来实现。为了防止在逐一签订协议过程中的相关问题,笔者在指导山东某县“城中村”改造中,运用附条件合同原理起草制订了实施方案,收到了较好效果。为便于交流、研讨,本文将该方案附后,以供实务部门参考。

附:山东省某县“城中村”改造协商搬迁实施方案

因“城中村”改造,需要搬迁全体村民的房屋,为顺利推动搬迁实现村民利益最大化,根据《中华人民共和国合同法》规定,本着平等、自愿的原则,特制定本方案。

一、搬迁范围

第一条 该改造项目需搬迁南至 ----- 东至 ----- 北至 ----- 西至 -----。

二、协商搬迁期限

第二条 评估等工作人员入户调查时,村民应配合并提供房产证、土地证、户口本、审批文件

是采用了隐瞒真实信息的方式促成了交易,虽然可以说替买卖双方节省了 time 成本,提高了资金或资本的使用效率,仍然难说是公平的。

从买卖双方的角度讨论完公平和效率的问题,我们再回顾一下过去专栏里面讨论“飞单”问题的时候提到的一个司法实践问题:如果经纪人与买卖双方签订的是居间合同,经纪人获取报酬的前提条件是促成合同成立,因此如果买卖双方认为他们之间的交易合同不是“这一个”经纪人促成的,而“这一个”经纪人又不能提供充足的证据,经纪人就无法获取佣金(经纪人只可以“要求

委托人支付从事居间活动支出的必要费用”),但如果是与其中一方签订的是委托合同,那么只要完成了合同所规定的服务事项,就可以要求委托方支付报酬。在司法实践中,法官判定委托合同成立所要求的条件往往比判定居间合同成立所要求的条件要低一些(或者更准确说:这两种合同需要提供的法律证据不一样,经纪人可以更容易地提供完成了委托服务的证据)。也就是说:即使从经纪人保护自身利益的角度看,与其中一方签订委托合同也比签订居间合同更有利。

王春敏 / 责任编辑